

第 34 問

以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について論じなさい（特別法違反の点を除く。）。

法科大学院受験を控えており、ストレスを抱えていた甲は、面白半分に、インターネットカフェから、インターネット上の掲示板に、A 駅において近いうちに無差別殺人を実行する旨の虚構の殺人事件の実行を予告し、不特定多数の者に閲覧させたところ、同掲示板を閲覧した者がその内容を警察に通報した。そのため、通報を受けた所轄警察署の警察官は、2 日間にわたり同駅構内等への出動、警戒等の業務に従事し、警ら、立番業務その他の本来業務を遂行することが困難になった。

甲は同掲示板を見た友人から、警察への通報がなされたこと、A 駅に警察官が出動したこと等を伝えられ、自分の行為が警察に知られるのではないかと不安になった。そこで、甲は、弟の乙に事情を全て打ち明け、「俺はもうすぐ法科大学院受験を控えているから、ここでバレるわけにはいかない。インターネット上の掲示板に書き込んだのは自分だと警察に言ってほしい。」などと言った。これを聞いた乙は驚いたが、甲を庇う気持ちから、やむなく警察に出頭し、警察官 B に対し、「無差別殺人予告をネット上に書き込んだのは僕です。」と虚偽の自供を行った。

しかし、B は、これを信用せず、甲について逮捕状を請求し、甲を逮捕した。

第1 甲が、インターネット上の掲示板に、虚構の殺人予告を書き込んだ行為について

偽計業務妨害罪（233後段）の成否が問題となるどころ、論点になるのは、公務が業務妨害罪の対象になるのか、という点である（**論点** 公務執行妨害罪・業務妨害罪における公務と業務  司H21J8H19-2）。

 190頁  79頁

この点につき、判例は、公務のうち、「強制力を行使する権力的公務」は、公務執行妨害罪のみの対象となるが、「強制力を行使する権力的公務」ではない公務は業務妨害罪でも処罰可能であると解する（最大判昭41.11.30、最決昭62.3.12、最決平12.2.17【百選Ⅱ23】、最決平14.9.30【百選Ⅱ24】等）。

ただし、警察官の職務といえば直ちにその全てが「強制力を行使する権力的公務」に当たるというわけではない。そこで、本問のような場合に、業務妨害罪が成立するかが、さらに問題となる。

本問の素材とした、東京高判平21.3.12は、「最近の最高裁判例において、『強制力を行使する権力的公務』が本罪にいう業務に当たらないとされているのは、暴行・脅迫に至らない程度の威力や偽計による妨害行為は強制力によって排除し得るからなのである。本件のように、警察に対して犯罪予告の虚偽通報がなされた場合（インターネット掲示板を通じての間接的通報も直接的110番通報と同視できる。）、警察においては、直ちにその虚偽であることを看破できない限りは、これに対応する徒勞の出動・警戒を余儀なくさせられるのであり、その結果として、虚偽通報さえなければ遂行されたはずの本来の警察の公務（業務）が妨害される（遂行が困難ならしめられる）のである。妨害された本来の警察の公務の中に、仮に逮捕状による逮捕等の強制力を付与された権力的公務が含まれていたとしても、その強制力は、本件のような虚偽通報による妨害行為に対して行使し得る段階にはなく、このような妨害行為を排除する働きを有しないのである。したがって、本件において、妨害された警察の公務（業務）は、強制力を付与された権力的なものを含めて、その全体が、本罪による保護の対象になると解するのが相当である」とした。

この東京高裁の考え方によれば、本問でも、偽計業務妨害罪の成立を認めることができるだろう。

なお、業務妨害罪の故意は、他人の業務を妨害し得る虚偽の風説を流布すること又は偽計を用いることの認識があれば足り、それ以上に、積極的に人の業務を妨害する目的意思を必要としないと解されている（大阪高判昭39.10.5）。そのため、甲に故意が認められることにも問題はない。

※ 虚構の殺人予告について脅迫罪（222）が成立する可能性もある。

この点について、同条の「人」には不特定多数者を含まないと解すれば、同罪は成立しない。一方で、「人」には不特定多数者を含むとした場合には、同罪は成立し得る。ただし、害悪が告知者の意思によって実現可能であると相手に思わせ得る加害内容でなければならないとされているところ、本問ではその内容が判然としないから、検討しなくてもよいだろう。

第2 乙が、身代わり犯として警察に出頭した行為について

1 乙の罪責

乙に、犯人隠避罪（103）が成立することは問題がない。「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいうところ、身代わり出頭をすることも「隠避」に当たる（大判大4.8.24）からである。なお、「隠避」該当性を基礎づけるロジックについては争いがあり、主に、犯人特定作用の危殆化を重視する見解と、究極的な身柄確保作用の危殆化を重視する見解に分かれる。

なお、本罪は、抽象的危険犯であると解されているから、Bが乙の自供を信用しなかった点については、本罪成立の障害とならない。

ただし、乙は、甲の弟であるから、105条の適用がある。

2 甲の罪責

犯人隠避罪の教唆犯の成否が問題となる（**論点** 犯人が自らの蔵匿・隠避を他人に教唆した場合の教唆犯の成否 **論** 旧H9-2）。

総論 284 頁 **論証** 149 頁

この点については、可罰的であると考えるのが判例（大判昭8.10.18）である。

さらに、上記のように、甲乙には親族関係があるから、乙に犯人隠避を教唆した甲にも、105条が準用されないかが問題となる（**論点** 犯人が自己の親族に対して蔵匿・隠避を教唆した場合の処理 **論** 旧H9-2）。

総論 287 頁 **論証** 151 頁

この点については、判例がなく、学説は、正犯である親族が任意的免除の適用を受けるのに準じて犯人もその適用を受けるとするとして同条を準用する見解、一方で、親族に対して教唆することにも期待可能性がないとはいえないとして準用を否定する見解に分かれる。なお、一般に、犯人隠避罪の教唆犯の成立を否定する見解からは、ここでもその成立が否定されることになる。

答案構成

第1 甲がインターネット上の掲示板に、虚構の殺人予告を書き込んだ点について

1 偽計業務妨害罪（233後段）の成否

↓

「偽計」とは、人を欺罔し、或いは人の錯誤又は不知を利用する違法な行為をいう

↓

あてはめ

↓

公務が「業務」に含まれるか

↓

強制力を行使する権力的公務は「業務」に含まれないが、そうではない非権力的公務は「業務」に含まれる
権力性の有無は個別具体的に判断する

↓

あてはめ

↓

2 故意（38 I）は、他人の業務を妨害し得る偽計を用いることの認識があれば足りる

↓

3 偽計業務妨害罪成立

第2 乙が、身代わり犯として警察に出頭した点について

1 乙の罪責

「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめる行為をいう

↓

身代わり行為もこれに当たる

↓

警察官Bがこれを信用しなかったとしても、影響なし

↓

105条の適用あり

2 甲の罪責

犯人隠避罪の教唆犯（61 I）

↓

可罰説

↓

105条準用の可否

↓

否定説

第3 罪数

甲には、偽計業務妨害罪及び犯人隠避罪の教唆犯が成立し、全て併合罪（45）となる

乙には、犯人隠避罪が成立するが、刑が任意的に免除される

第1 甲がインターネット上の掲示板に、虚構の殺人予告を書き込んだ点について

1 この書き込みが警察に通報された結果、所轄警察署警察官が2日間にわたり、出動・警戒等し、本来の業務の遂行が困難になっている。

これは「暴行又は脅迫」に当たらないから、公務執行妨害罪（95条）は成立しないものの、偽計業務妨害罪（233条後段）が成立するのではないか。

(1) 「偽計」とは、人を欺罔し、或いは人の錯誤又は不知を利用する違法な行為をいうところ、上記の虚構の殺人予告は、これに当たる。

(2) 次に、公務が「業務」に含まれるかが問題となる。

この点について、強制力を行使する権力的公務については威力・偽計は実力で排除できるが、そうではない非権力的公務についてはそのような実力はない。しかも、非権力的公務は一般私人の業務と区別する必要がなく、「業務」に当たるとしても無理はない。

したがって、非権力的公務のみが「業務」に含まれるとするのが妥当である。なお、権力性の有無は個別具体的に判断すべきである。

本問では、上記書き込みがなければなされたであろう本来の警察業務は、警ら、立番業務等であるが、その中には、逮捕状による逮捕等の強制力を付与された権力的公務が含まれている可能性があるが、その強制力は、虚偽の書き込みによる妨害行為に対して行使し得る段階にはなく、その妨害行為を排除する働きを有しない。

したがって、非権力的公務であり、「業務」に当たる。

1

2 また、業務妨害罪の故意としては、他人の業務を妨害し得る偽計を用いることの認識があれば足り、それ以上に、積極的に人の業務を妨害する目的意思を必要としない。

そのため、甲には、故意も認められる。

3 以上から、甲には、「偽計を用いて、人の……業務を妨害した」として、偽計業務妨害罪が成立する。

第2 乙が、身代わり犯として警察に出頭した点について

1 乙の罪責

(1) 乙は、上記甲の罪に関して、警察に出頭し、警察官Bに虚偽の自供をするなど、身代わり行為に及んでいるが、この行為は、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめる行為たる「隠避」に当たり、乙には、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を「隠避させた」として、犯人隠避罪（103条）が成立する。

なお、本罪は抽象的危険犯であるから、警察官Bが乙の出頭行為を信用せず、甲を逮捕した点は、本罪の成否に影響しない。

(2) もっとも、乙は甲の弟であるから、「親族」に当たり、105条により刑が任意的に免除される。

2 甲の罪責

(1) 甲は、乙に対し、上記の出頭及び虚偽の自供をそそのかしているから、犯人隠避罪の教唆犯（61条1項）となり得る。

(2) もっとも、103条の主体に犯人自身が含まれておらず、正犯が成立しない以上、より軽い教唆犯も成立し得ないのではないかが問題と

2

なる。

この点について、同条の犯罪の主体には犯人が含まれていないのは、犯人には適法行為の期待可能性がないからである。そうすると、犯情において軽い教唆犯については、なおさら期待可能性が存せず、教唆犯は成立しないと思われる。

しかし、共犯の処罰根拠は、正犯を介した間接的な法益侵害に求めるべきである。そうだとすれば、正犯に犯罪が成立する以上、これを教唆すれば法益侵害を引き起こしているといえることができる。

しかも、他人を利用して自己を蔵匿・隠避させることは、自ら蔵匿・隠避するよりもそれが容易になるから、その意味で法益侵害の程度はより高い。

また、かかる事態にあつては、定型的に期待可能性がないということではできないし、他人を利用して蔵匿・隠避を図ることは防御権の濫用である。

したがって、犯人が他人に隠避を教唆した場合は、教唆犯が成立するとみるべきである。

- (3) もっとも、上記のように、甲及び乙には親族関係があるから、乙に犯人隠避を教唆した甲にも、105条が準用されないか。

同条の趣旨は、親族を隠避させることにおいて期待可能性がない点に求められる。

一方、犯人が第三者に対して蔵匿・隠避を教唆することに期待可能性がないとはいえない。そして、この理は親族を教唆した場合でも妥

3

当するから、同条の準用は認められないと解すべきである。

したがって、犯人には同条を準用すべきではない。

甲には105条の準用は認められない。

第3 罪数

甲には、偽計業務妨害罪及び犯人隠避罪の教唆犯が成立し、全て併合罪(45条)となる。

乙には、犯人隠避罪が成立するが、刑が任意的に免除される。

以上

4